

致的情况下，不能仅仅因为劳动者的沉默而认为变更劳动合同有效。

综上，《中华人民共和国劳动合同法》之所以规定变更劳动合同应当采用书面形式：一是因为《中华人民共和国劳动合同法》规定建立劳动关系应当订立书面劳动合同；二是采用书面形式有利于明确双方的权利义务关系，遇有纠纷时方便举证；三是书面形式的劳动合同有利于控制合同内容，方便劳动行政部门对劳动合同进行审查和监督。总之，法律之所以规定书面形式，实际是为了规范用人单位的管理，避免用人单位利用优势地位侵害劳动者的权益。但现实生活中，特别是在中小企业的治理机制不健全的情况下，如果一味机械恪守书面形式的规定，一些有利于劳动者的变更被判定为无效，对劳动者往往不利，这与将劳动合同的变更规定为要式的目的背道而驰。

二、附条件的薪酬条款变更的法律效力认定

附条件的薪酬条款变更与前述劳动合同协商变更既相互关联又侧重不同。

首先，上述条款的变更应当按照劳动合同变更的规范进行审查，如果双方不具备书面形式的变更，则应当按照《劳动争议解释(一)》第四十三条规定审查是否符合《劳动争议解释(一)》第四十三条规定的三个条件，如果欠缺口头协商一致的依据，即使劳动者沉默超过一个月，也不能认定其默示同意薪酬条款的变更，特别是上述薪酬条款变更对劳动者不利的情况，需要作出更为审慎的判断。

其次，如果上述变更符合劳动合同协商变更的要式性后，应对附加条件本身的性质进行审查。劳动者和用人单位一旦建立劳动关系，则有了实际上的管理与被管理的关系，故而在司法实践中应当对当事人合意予以尊重，另外，也应当对用人单位行为的合法性、合理性进行审查，以保护劳动者的合法权益。具体可从以下两个方面进行分析：一是附条件应该限定在法律规定的范围以内，不能逾越法律关于工资分配规则和工资水平限制等，如不得通过附加条件将劳动者的劳动报酬实际调整到最低工资标准以下；二是该自主权的行使不能由用人单位依单方意愿决定，必须与劳动者形成合意，才具有法律效力。

最后，附条件变更的效力具有相对性。附条件民事法律行为，是指当事人

以未来客观上不确定发生的事实作为民事法律行为效力的附款。同样，所谓附条件变更也是以未来客观上不确定发生的事实作为变更的条件，因此该变更具有相对性。换言之，即使用用人单位与劳动者就该变更达成一致，且相关变更已经实际履行超过一个月，同时也不存在违反法律、行政法规和违背公序良俗，其效力也取决于所附条件实际是否能够达成。如果用人单位一方面设定了所附条件，另一方面又积极促成双方关系脱离所附条件约束，实际上是破坏了该所附条件的效力基础，依法可认定无效，从而使双方权利义务关系恢复到合同未变更的情形和状态。

编写人：广东省广州市荔湾区人民法院 巫仕平 张建锋 何涵晗

“长期两不找”状态下劳动关系的认定

——喻某诉某机械公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省内江市中级人民法院（2023）川10民终1102号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告（上诉人）：喻某

被告（被上诉人）：某机械公司

【基本案情】

某机械公司原名为某精密焊管公司。

1995年8月，喻某由技校毕业分配至某机械厂模具分厂工作。2005年，某

机械厂政策性破产重组为某精密焊管公司。2016年年底,某机械公司进行内部体制改革,将喻某工作的模锻工厂租赁给某模具制造公司生产经营。2017年1月起,某机械公司安排喻某到某模具制造公司工作,并与喻某保留劳动关系,且喻某的社会保险依然由某机械公司负责缴纳。2017年1月至2019年4月,喻某在某模具制造公司工作,由某模具制造公司代某机械公司管理并代为支付劳动报酬。自2019年5月起喻某未向某模具制造公司提供劳动,也未回到某机械公司处继续工作向其提供劳动,某机械公司也未向喻某支付劳动报酬。某机械公司为喻某缴纳社会保险至2019年9月。

2019年9月18日,喻某向某模具制造公司提交了《解除劳动关系通知书》。2022年12月20日,喻某向某机械公司邮寄了《被迫解除劳动合同通知书》,向某机械公司提出解除劳动合同。

喻某认为,喻某在某机械公司改制后的工作年限为16年,即2006年至2022年。自2020年起喻某曾多次要求回到某机械公司处上班,要求某机械公司继续履行劳动合同,但某机械公司既未安排喻某工作、未支付喻某的生活费,也未与喻某解除劳动合同和办理相关手续。最后喻某被迫向某机械公司发出了《被迫解除劳动合同通知书》,双方的劳动关系现已解除。为此,喻某申请劳动仲裁,隆昌市劳动人事争议仲裁委员会于2023年3月24日作出仲裁裁定,裁决如下:对喻某的所有仲裁请求不予支持。喻某对该裁定不服,提起诉讼,要求某机械公司依法支付喻某解除劳动合同的经济补偿金、赔偿金等。

【案件焦点】

长期“两不找”状态下的劳动关系如何认定。

【法院裁判要旨】

四川省隆昌市人民法院经审理认为:喻某自2019年5月起未向某机械公司 提供劳动,某机械公司也未向喻某支付劳动报酬,双方未再履行劳动关系的权 利和义务,可以认定劳动关系处于事

实解除状态。喻某诉称自2020年至2022 年通过邮寄的方式向某机械公司邮寄了书面申请书，要求某机械公司继续履行

劳动合同，但其提供的证据不足以证明其主张。喻某以某机械公司未为本人安排工作，提供劳动条件，依法缴纳社会保险为由的解除劳动合同的理由不能成立，双方解除劳动关系不符合用人单位应当支付经济补偿金和赔偿金的情形，故对喻某的诉讼请求，依法不予支持。

四川省隆昌市人民法院判决如下：

驳回喻某的诉讼请求。

喻某不服一审判决，提出上诉。四川省内江市中级人民法院经审理认为：关于某机械公司与喻某之间的劳动合同何时解除及解除的原因的问题。喻某自2019年5月起未再向某机械公司提供劳动，某机械公司也未再向喻某支付劳动报酬，双方劳动关系仍然存续，但在此期间双方不享有和承担劳动法上的权利义务，直至出现法律规定的事由双方劳动关系才解除或终止。本案中，喻某于2022年12月20日向某机械公司邮寄《被迫解除劳动合同通知书》，某机械公司的工作人员于2022年12月22日收到该通知书。综上，某机械公司与喻某之间的劳动合同于2022年12月22日解除，解除的原因系喻某依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定向某机械公司提出解除。

关于喻某申请仲裁是否已超过一年仲裁时效的问题。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条的规定，喻某与某机械公司之间的劳动合同于2022年12月22日解除，喻某向隆昌市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，隆昌市劳动人事争议仲裁委员会于2023年2月13日受理，未超过一年仲裁时

效，某机械公司关于喻某申请仲裁已经超过一年仲裁时效的辩称理由不能成立，法院不予采信。

关于某机械公司是否应当支付喻某解除劳动合同的经济补偿金及赔偿金。本案系喻某依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定向某机械公司提出解除劳动合同的情形，而不是用人单位违法解除或终止劳动合同的情形，故某机械公司无须依照《中华人民共和国劳动合同法》第八十七条规定支付喻某赔偿金。经查明，某机械公司不存在拒不提供劳动条件、未及时足额支付劳动报酬以及未依法缴纳社会保险费等情形，喻某要求某机械公司支付解除劳动

合同经济补偿金及赔偿金的理由不能成立。

四川省内江市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及“长期两不找”状态下劳动关系的认定问题。

一、“长期两不找”的概念及主要情形

“长期两不找”并非法律概念，而是在司法实践中出现的一种不规范的劳动关系状态，即用人单位与劳动者建立劳动关系后，劳动者长期未向用人单位提供劳动，用人单位也长期未向劳动者发放工资、提供福利待遇等，但用人单位与劳动者也未有效地解除或者终止劳动关系，双方处于互不履行劳动权利义务的状态。

“长期两不找”的出现，主要源自用人单位劳动管理不规范。一般有两种情形：一是“停薪留职”协议期满后，劳动者未回到原单位工作也没有办理辞职手续，单位也未按照“自动离职”作出处理；二是劳动者“不告而别”自行离职，用人单位未及时办理解除劳动关系的手续，或者未将解除劳动关系的通知送达给劳动者。

“长期两不找”中由于用人单位没有与劳动者办理解除(终止)劳动关系手续，存在潜在的问题。劳动者或者找到原单位主张确认劳动关系，要求用人单位补发工资福利待遇补贴、补缴社会保险费、办理退休手续等，或者以用人单位未及时缴纳社会保险费、违法解除劳动合同为由要求其支付经济补偿金、违法解除劳动合同赔偿金等。“长期两不找”在法律上到底属于何种劳动关系，在司法实践中也存在一定争议。

二、“长期两不找”的劳动关系认定问题

如何认定“长期两不找”的劳动关系并界定双方权利义务的范围，司法实践中主要存在三种观点：第一种观点认为，劳动关系自劳动者离开用人单位之日解除，劳动者无权向用人单位主张相关权利。理由是劳动者离开用人单位后，

双方之间实际上已经长期没有互相履行劳动权利义务，从公平的角度应承认双方的劳动关系为事实解除。第二种观点认为，劳动关系一直持续，劳动者有权主张福利待遇、补缴社会保险等。理由是，劳动关系依法建立，也应当依法解除，我国劳动法律并无劳动关系自行消灭的规定，而双方未正式履行解除劳动关系的程序，用人单位对此应当负有管理不规范的责任。第三种观点认为，双方的劳动关系从劳动者离开用人单位之日起，至任何一方提出解除劳动关系的意思表示到达对方之日止，此期间双方的劳动关系处于中止状态，双方互不履行劳动权利义务，劳动者不得向用人单位主张工资报酬、福利待遇、社会保险等，中止期间不计入本单位工作年限。

笔者同意第三种观点，理由如下：

1. 认定劳动关系中止符合双方真实意思表示。《中华人民共和国合同法》第七条规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。支持劳动关系自离岗之日解除的观点认为，既然法律认可事实劳动关系，自然也应当允许事实解除劳动关系，这种观点显然失之偏颇。事实上，我国承认事实劳动关系的合法地位旨在通过确认劳动关系不依赖书面合同而存在，进而扩大劳动保护范围，其根本立足点在于双方本身具有建立劳动关系的明确合意。而“长期两不找”中，劳动关系没有经过法定程序予以解除或终止，劳动者与用人单位对于是否解除劳动合同并无明确、有效的意思表示，实际处在一种不确定的状态。人民法院应当尊重劳动者的自主择业权与用人单位的用工自主权，以双方明确的意思表示为前提，在双方意思表示不明确的情况下，不宜径直以默认或推定的方式认定双方劳动关系已经解除。

2. 认定劳动关系中止符合“按劳分配”“权利义务相统一”原则。《中华人民共和国劳动法》第四十六条第一款明确规定：“工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。”按劳分配，就要充分体现多劳多得、少劳少得、不劳不得。“长期两不找”中，双方之间实际上已经长期没有互相履行劳动权利义务，劳动者不受用人单位规章制度约束，不受用人单位管理，不参加用人单位劳动，用人单位也不向劳动者支付工资、福利待遇等。此种劳动关系本质上

